

1503277-96.2021.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marina Freire

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - TRÁFICO DE DROGAS - CRIME PERMANENTE - NULIDADE INEXISTENTE - ASSOCIAÇÃO CRIMINAL - ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO. Em razão do caráter permanente do delito de tráfico de drogas, o flagrante é possível a qualquer momento, não constituindo ilegalidade o ingresso de policiais na residência do suspeito, mesmo sem mandado de busca e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503277-96.2021.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Averiguado:

VAGNER DE LIMA TARDIVO JUNIOR

Juíza de Direito: Dra. Marina Freire

Vistos.

VAGNER DE LIMA TARDIVO JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 13 de novembro de 2020, por volta de 22h45, na Rua Ângelo Vianelo, nº 14, Residencial Nova Bauru, nesta cidade e Comarca de Bauru, guardava 343,19 g de entorpecente conhecido como tenanfetamina (MDA), divididos em 940 comprimidos, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Oferecida a denúncia (fls. 1/3), por decisão de fls. 48/49 foi determinada a notificação do réu.

O réu foi notificado (fl. 57) e apresentou defesa prévia (fls. 62/63).

A decisão de fls. 65/67 recebeu a denúncia e deu início à fase de instrução processual, procedendo-se à oitiva de duas testemunhas comuns e ao interrogatório do réu (fl. 90-mídia).

Superada a fase de diligências, em alegações finais o representante do Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, uma vez que entendeu provados os fatos narrados na denúncia, bem como a materialidade e a autoria delitivas (fls. 94/97).

Em outro ângulo, a Defesa preliminarmente rogou pelo reconhecimento da nulidade do processo, uma vez que as provas dos autos foram obtidas por meios ilícitos, tendo em vista a violação de domicílio. Quanto ao mérito, pugnou pela absolvição diante da ausência de provas e de elementos para corroborar um édito condenatório. Subsidiariamente, em caso de condenação, sustentou e pleiteou a desclassificação do delito para a figura do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Ainda, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, bem como fixação de regime inicial aberto, substituição da pena corporal por restritiva de direitos e autorização para recorrer em liberdade (fls. 101/150).

É o relatório.
DECIDO.

De início, repilo a preliminar ventilada pela Defesa quanto à nulidade das provas sob o argumento de violação de domicílio, haja vista que, no caso concreto, os policiais receberam informação da prática do tráfico de drogas pelo réu, sua localização e suas características físicas, de modo que, ao efetuarem patrulhamento e ao encontrá-lo, procederam à abordagem e efetuaram questionamentos acerca da mercancia, tendo o réu acabado por admitir a prática criminosa e autorizado o ingresso dos militares em sua residência, onde foram localizados os estupefacientes, motivo pelo qual não há se falar em violação de domicílio.

Outrossim, apenas por amor aos debates, cabe acentuar que o delito em análise se trata de crime permanente, o qual autoriza a entrada policial no domicílio, com ou sem mandado judicial, em evidente estado de flagrância. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - TRÁFICO DE DROGAS - CRIME PERMANENTE - NULIDADE INEXISTENTE - ASSOCIAÇÃO CRIMINAL - ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO. Em razão do caráter permanente do delito de tráfico de drogas, o flagrante é possível a qualquer momento, não constituindo ilegalidade o ingresso de policiais na residência do suspeito, mesmo sem mandado de busca e apreensão, pois a regra constitucional da inviolabilidade do lar não socorre agente em situação flagrancial. [...] (TJMG. 4ª Câmara Criminal. Apelação Criminal 1.0290.18.004394-2/001. Relator: Des. Fernando Caldeira Brant. Data do julgamento: 16 de outubro de 2019) (destaquei)

Ainda, cabe ressaltar a sólida jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

[...] 7. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que, nos casos de crime permanente, não há ilegalidade na busca e apreensão por violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a entrada da autoridade policial seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial. Habeas corpus não conhecido. (STJ. Quinta Turma. HC 309.567/CE. Relator: Min. Joel Ilan Paciornik. Data do julgamento: 3 de abril de 2018)

De mais a mais, ainda a título de argumentação, nenhum direito fundamental é absoluto. O princípio da proporcionalidade deve ser levado em consideração quando houver conflito entre duas garantias constitucionais e, se observado um confronto entre a inviolabilidade domiciliar e a segurança pública, deve esta preponderar.

Por consequência, não há se falar em provas produzidas por meios ilícitos, afastando-se a preliminar arguida.

Alijando a matéria preliminar aventada, passo à análise do mérito.

Pois bem. Trata-se de ação penal pública instaurada para a apuração do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

As provas amealhadas nos autos ao longo da dilação probatória, ao contrário do alegado pela Defesa, autorizam a procedência do pedido inicial.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 7/8, auto de exibição e apreensão de fl. 11, laudo toxicológico definitivo de fls. 15/17, laudo de constatação provisória de fls. 20/22, laudo complementar de fls. 37/41, além da prova oral produzida em Juízo.

A autoria, por igual, delinea-se indubitosa.

O réu negou a prática do delito. Disse que adquiriu as porções de entorpecente pela quantia de R\$ 200,00 a fim de consumir em festas, na companhia de seus amigos. Negou que iria comercializar as drogas. Explicou que não passava por necessidades financeiras. Aduziu que foi abordado pelos policiais e indicou onde era sua residência, porém não autorizou o ingresso dos militares no imóvel, assim como afirmou que no local não havia odor de maconha. Acrescentou ter comprado o estupefaciente porque o preço era baixo (fl. 90-mídia).

O policial militar Edi Nilton de Azevedo relatou ter recebido notícia de que indivíduo chamado Wagner, o qual possuía tatuagem no pescoço e permanecia nas proximidades de uma barbearia situada na Rua Ângelo Vianelo, estava armazenando drogas sintéticas. Falou que se dirigiu ao local e encontrou o réu, indivíduo portador das características informadas, sendo que nada de ilícito com ele foi encontrado; ao ser questionado acerca da existência do estupefaciente, inicialmente o réu negou, todavia posteriormente acabou admitindo que havia droga em sua residência, tendo indicado a localização, franqueado o acesso ao imóvel e mostrado onde o entorpecente estava guardado. Asseverou que foram encontradas cerca de mil porções de ecstasy e o réu afirmou que iria vendê-las em uma festa que aconteceria em Bauru. Mencionou que havia odor de maconha na casa e o réu admitiu que havia adquirido e comercializado 2 kg da droga. Esclareceu que o réu justificou a prática criminosa porque estava desempregado. Por fim, reportou que não havia outras pessoas no imóvel (fl. 90-mídia).

No mesmo sentido, o policial João Victor Contelli Xavier narrou que uma pessoa compareceu à base do BAEP e informou que um indivíduo com tatuagens no braço e no pescoço, conhecido como "Biu", frequentador de uma barbearia situada na Rua Ângelo Vianelo, Residencial Nova Bauru, estava armazenando drogas e iria comercializá-las em festas; ato contínuo, em patrulhamento pelas imediações do endereço, avistaram o réu, pessoa com características semelhantes àquelas informadas, e procederam à abordagem. Contou que o réu inicialmente negou a existência dos estupefacientes, no entanto durante a entrevista admitiu que havia comprado drogas a fim de vendê-las em festas, pois estava precisando de dinheiro, bem como noticiou que o entorpecente estava escondido em sua casa, indicando a localização exata em seu quarto. Aduziu ter encontrado pacote plástico contendo diversos comprimidos armazenados em embalagem plástica, quando então o réu afirmou ser ecstasy e iria comercializar em festa rave. Acrescentou que havia forte odor de maconha no quarto e o réu esclareceu que havia vendido certa quantidade desse entorpecente (fl. 90-mídia).

Ao que se extrai das provas documental e oral colhidas nos autos, bem como observada a dinâmica dos fatos, não persistem dúvidas no tocante à responsabilidade do réu pela prática do tráfico de drogas.

As circunstâncias evidenciam a prática do delito nas modalidades "ter em depósito"

ou “guardar”, verbos nucleares trazidos pelo tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Como se observa, os policiais militares foram uníssonos e categóricos ao afirmar como se deram os fatos, haja vista que receberam notícia de que o réu tinha entorpecentes em depósito, efetuaram patrulhamento e procederam à abordagem, quando então o réu admitiu a existência de drogas em sua residência, onde foram encontrados 940 comprimidos de tenanfetamina (MDA).

A propósito, nada há nos autos capaz de retirar o valor probatório dos depoimentos dos policiais, os quais apresentaram as mesmas versões em ambas as fases do procedimento, razão pela qual merecedores de credibilidade. A essência dos depoimentos dos agentes revelou-se, em sua substância, uniforme e factível em Juízo.

Com efeito, não podem ser desconsiderados os depoimentos dos militares, servidores públicos cumpridores de seus deveres, já que foram compromissados como qualquer outra testemunha e não possuem interesse em incriminar o réu. Necessário ressaltar que a função da Polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos agentes, razão pela qual não merecem ver desprestigiadas suas palavras somente pelo fato de pertencerem ao quadro da Polícia. Nesse sentido:

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que eles foram submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

[...]

Ressalte-se que, como é cediço, policiais não estão legalmente impedidos de depor em processos nos quais tenham participado da fase investigativa, revestindo-se suas palavras de relevante valor probatório, mormente quando prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Ademais, nada de concreto foi trazido aos autos no sentido de infirmar os seus relatos, sendo certo que não teriam razão alguma para imputar a prática de infração tão grave a pessoas que sabem ser inocentes. (TJSP. 11ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001971-89.2017.8.26.0530. Relator: Salles Abreu. Data do julgamento: 3 de outubro de 2018)

TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA.

1. Para se desconstituir o édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

(STJ. HC nº 267.025 – DF. Relator: Ministro Jorge Mussi. Data do julgamento: 02 de maio de 2013) (destaquei)

Ora, diante de toda prova produzida e com riqueza de detalhes de como se deram os fatos, não há se falar em fragilidade probatória a ponto de propiciar a absolvição

do réu.

Da análise do boletim de ocorrência de fls. 7/8, auto de exibição e apreensão de fl. 11, laudo toxicológico definitivo de fls. 15/17, laudo de constatação provisória de fls. 20/22, laudo complementar de fls. 37/41, nota-se que foram apreendidos 940 comprimidos (343,19 g) de tenanfetamina (MDA).

Não fosse pela prova oral produzida, já tão suficiente à condenação, a quantidade dos produtos apreendidos encerra circunstâncias que, analisadas em conjunto, induzem à certeza da destinação ao comércio.

Igualmente, para a consumação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, crime permanente, basta a prática da conduta do núcleo do tipo, ou seja, uma das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

É certo também que a legislação antidrogas estabelece que, para a caracterização do crime de tráfico, mister a análise da natureza da droga, sua quantidade, avaliação do local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente de drogas. A quantidade de entorpecente apreendido tem sido referencial na jurisprudência brasileira para caracterização do ilícito da mercancia. Claro que não basta essa única circunstância. Todo conjunto probatório leva à responsabilização do réu. Nesse sentido:

[...] 5. Tráfico de drogas e uso de substância entorpecente. O fato do réu não ter sido preso em atos de traficância, por si só, pouco importa, afinal, o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de um dos dezoito verbos núcleos do tipo, previstos no preceito primário do referido dispositivo legal ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas"), a Lei Especial não exigindo que o agente esteja em atos de mercancia, até porque tipifica como crime a prática das condutas acima mencionadas ainda que "gratuitamente". Precedentes do STJ [...] (TJSP. 3ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001686-11.2011.8.26.0400. Relator: Des. Airton Vieira. Data do julgamento: 10 de outubro de 2017)

De se notar que, embora o réu negue o tráfico, afirmando ser usuário e tentando justificar o entorpecente apreendido, é certo que tal negativa não passou de uma tentativa da Defesa para desclassificar o delito.

Aliás, a alegação de ser usuário não alija a traficância. Muitos traficantes buscam como meio de defesa a desclassificação da infração penal. E, neste ponto, saliento não ser uma situação excludente da outra.

Por todo o exposto, entendo que o quadro probatório formado ao longo da instrução autoriza a conclusão do cometimento, pelo réu, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Concluindo pela condenação, passo à dosimetria da pena.

De acordo com o artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade do réu não merece maior reprovação, pois ficou estrita à prática do delito. O réu não ostenta antecedentes criminais. Não há nada nos autos a respeito de sua conduta social e sua personalidade, assim reputo-as em seu favor. O motivo do crime é o comum: expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia. As circunstâncias e as consequências do delito não levam à exasperação da pena.

Destarte, por inexistir circunstância judicial contra o réu, fixo a pena para esta

fase no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, devendo ser mantida a sanção anteriormente fixada, não havendo se falar em atenuante da confissão espontânea, pois realizada de forma parcial e de encontro à totalidade da prova dos autos, uma vez que o réu apenas afirmou que os entorpecentes seriam destinados ao uso próprio. Aliás, é de fundamental importância enfatizar o teor do enunciado da Súmula nº 630 do STJ:

SÚMULA N. 630. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena. Também não é possível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido (940 comprimidos de tenanfetamina - MDA), fato que revela a dedicação do réu a atividades delitivas, com a existência de uma estrutura voltada à prática da traficância, não se tratando de traficante eventual. Nesse sentido:

Apelação Criminal- Tráfico de Drogas- Recurso Defensivo- Autoria e materialidade comprovadas- Defesa que pleiteia somente reforma na dosimetria da pena- Redução da pena-base ao mínimo legal-A quantidade do entorpecente apreendido não pode ser levada em consideração, conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, na primeira e na terceira fases da dosimetria, cumulativamente, sob pena de se incorrer em bis in idem -Atenuante da confissão reconhecida, em observância ao enunciado 231, do STJ- Incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas- Defesa que pleiteia o reconhecimento do tráfico na modalidade privilegiada- Impossibilidade- Apreensão de 3370 comprimidos contendo 1.228,7g de "MDA" (tenanfetamina)- Expressiva quantidade de droga sintética, de extremo potencial lesivo- Redutor incabível -Maior gravidade da conduta e gravidade concreta do delito-Regime prisional inicial fechado único possível - Substituição penal inviável-Sentença parcialmente reformada, sem reflexos na pena- Recurso defensivo parcialmente provido. (TJSP. 8ª Câmara de Direito Criminal. Apelação Criminal nº 1500391-69.2021.8.26.0542. Relator: Des. José Vitor Teixeira de Freitas. Data do julgamento: 4 de setembro de 2021) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 130 PEDRAS DE CRACK. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. [...] 2. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida em poder do acusado constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à minguada do preenchimento dos requisitos legais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ. 6ª Turma. AgRg no Ag nº 1.295.751 PR. Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. Data do julgamento: 14/05/2013) (destaquei)

Dessa forma, torno definitivas as penas de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Malgrado a quantidade de pena hipoteticamente autorizasse o início do cumprimento em regime semiaberto, é preciso sempre deixar claro que se trata de delito de tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado ao crime hediondo (art. 5º, XLIII, da CF/88) e que a própria Carta Magna previu tratamento diferenciado, mais rigoroso, em razão da nocividade desse delito para o bem-estar social. Além disso, o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007, dispõe

que será cumprida inicialmente em regime fechado a pena por crime de tráfico de drogas. Outrossim, embora haja decisões das Cortes Superiores concedendo tais benesses, é certo que não possuem efeito erga omnes nem vinculante, de modo que a convicção dessa magistrada está preservada no tocante à análise do caso in concreto. De mais a mais, a fixação do regime fechado é imprescindível à prevenção e repressão do crime cometido, de modo a atender o princípio da suficiência da pena (artigo 59 do Estatuto Repressivo). Assim, o regime inicial será o fechado.

Por fim, nos termos do artigo 44 da Lei nº 11.343/2006, é vedada a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, além, é claro, do não atendimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR o réu VAGNER DE LIMA TARDIVO JÚNIOR à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos para cada dia-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pena a ser cumprida em regime inicial fechado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento e comunique-se à Vara de Execuções Penais, Instituto de Identificação e Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da Constituição Federal).

O réu respondeu ao processo em liberdade. Além disso, não se vislumbram os requisitos autorizadores da prisão preventiva, de sorte que concedo a ele o direito de recorrer em liberdade.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Bauru, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA